

MAIZATUL AZNIN BINTI MOHAMED

lwn

SALIHIN BIN ISMAIL

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Tuan Hj Saarani bin Ismail (Pengerusi), YA Prof. Adjung Dato' Dr Hj. Mohd Naim bin Hj. Mokhtar (Panel), Y.A Tuan Hj. Mohd Amran bin Mat Zain (Panel), Pada 13 Julai 2018]

[Permohonan No. 10000-028-0046-2017]

[Rayuan Tuntutan Hadhanah]

Peguam Syarie Pemohon: Puan Nursahila binti Ayub dari Tetuan Azaine & Fakhrul

Peguam Syarie Responden: Hisyam bin Yusof dari Tetuan Wan Adnan & Associates.

ALASAN PENGHAKIMAN

1. Kes ini adalah suatu rayuan oleh Perayu terhadap **sebahagian** keputusan Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah bertarikh 17/4/2017 dalam Kes Mal No : 10400-028-0038-2015 dan sebahagian perintah tersebut adalah sebagaimana berikut:-

- i. Mahkamah memerintahkan Defendan (bapa) hendaklah diberikan hak lawatan dan bermalam ke atas anak yang bernama Mohsin bin Salihin (No. My Kid : 120406-10-1933) pada hujung minggu kedua dan keempat setiap bulan bermula dari jam 12.00 tengahari Jumaat dan hendaklah dikembalikan semula kepada Plaintiff pada hari Ahad jam

6.00 petang dengan urusan pengambilan hendaklah dimaklumkan kepada Plaintiff terlebih dahulu.

- ii. Mahkamah memerintahkan Defendan (bapa) hendaklah diberikan hak lawatan ke atas anak yang bernama Mohsin bin Salihin (No. My Kid : 120406-10-1933) pada hari Isnin dan Rabu minggu pertama dan minggu ketiga serta hari Selasa dan Khamis minggu kedua dan keempat setiap bulan antara jam 6 petang sehingga jam 9 malam dengan memaklumkan terlebih dahulu kepada Plaintiff.

Fakta Kes

2. Perayu dengan Responden adalah merupakan bekas suami isteri . Pihak-pihak telah bernikah pada 2/10/1999 di Sg Rapat, Ipoh Perak dan telah bercerai pada 1/6/2016 di Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam, Selangor. Hasil daripada perkahwinan tersebut, mereka telah dikurniakan tiga (3) orang anak iaitu :-

- i. Mifzal bin Salihin
- ii. Muqrish bin Salihin
- iii. Mohsin bin Salihin

3. Perayu telah menfailkan tuntutan hak jagaan anak ke atas anak-anak tersebut pada 26/4/2015. Pada 17/4/2017 Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam telah memutuskan sebagaimana di muka surat 231-233 Rekod Rayuan.

4. Perayu telah tidak berpuashati dengan keputusan tersebut dan memfailkan Notis Rayuan pada 28/4/2017 untuk merayu sebahagian dari keputusan berkenaan hak bermalam dan hak melawat anak yang bernama Mohsin bin Salihin.

5. Responden pula pada 18/5/2018 telah memfailkan Notis Rayuan Balas ke atas anak ketiga tersebut sebagaimana di halaman 183 rekod rayuan.

6. Perayu dalam rayuan ini telah mengemukakan 4 (empat) alasan rayuan sebagaimana berikut:

1. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi undang-undang dan fakta apabila memutuskan hak lawatan dan bermalam ke atas anak yang bernama Mohsin bin Salihin (No. My Kid : 120406-10-1933) (*selepas ini akan dirujuk sebagai "anak ketiga tersebut"*) tanpa mengambil keterangan dan/atau fakta dari Plaintiff dan hanya mengambilkira cadangan dan/atau permintaan dari Defendan.
2. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari fakta apabila memutuskan hak lawatan dan hak bersama anak ketiga tersebut tanpa mengambilkira jadual persekolahan dan kelas tambahan anak tersebut.
3. Yang Arif telah terkhilaf dari undang-undang dan fakta apabila tidak mengutamakan kemaslahatan dan kebajikan anak ketiga tersebut apabila telah menetapkan waktu lawatan bersana Defendan pada waktu malam tanpa mengambilkira keperluan lain anak ketiga tersebut seperti keperluan atas pelajaran dan waktu rehat pada waktu tersebut.

4. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta undang-undang dan hukum syarak kerana menurut *Kitab Fiqh & Perundangan Islam Jilid IV oleh Wahbah Zuhaili*, tidak dibincangkan berkenaan garis panduan di dalam penentuan hak lawatan, bersama dan bermalam dan hanya dibincangkan berkenaan hak menziarahi anak yang tidak berada di dalam jagaanya.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

7. Sebelum kami menjawab isu rayuan Perayu di atas, kami mengambil maklum bahawa di dalam Penghujahan Perayu telah dibangkitkan penghujahan ketidakpatuhan mengenai tempoh pemfailan Notis Rayuan Balas yang difailkan oleh Responden. Ingin kami tegaskan di sini bahawa sekiranya mana-mana pihak berhasrat untuk membantah mengenai ketidakpatuhan sesuatu prosedur, pihak yang membantah tersebut hendaklah membuat bantahan terhadap ketidakpatuhan prosedur tersebut dengan memfailkan pliding-pliding berkaitan mengikut peruntukkan undang-undang sebaik sahaja pihak yang membantah itu menyedari ketidakpatuhan prosedur telah berlaku dan bukannya dimasukkan bersekali dengan penghujahan terhadap merit rayuan. Di dalam kes ini, sekiranya Perayu ingin membantah mengenai ketidakpatuhan mengenai tempoh pemfailan Notis Rayuan Balas, sepatutnya Perayu memfailkan Notis Bantahan Awal terhadap isu tersebut semasa pengurusan kes rayuan lagi dan bukannya dimasukkan bersekali dengan penghujahan terhadap merit rayuan. Oleh yang demikian, kami tidak akan mengulas isu ketidakpatuhan yang dihujahkan Perayu yang dibangkitkan di dalam penghujahan di peringkat merit rayuan ini.

8. Berbalik kepada merit rayuan ini, setelah kami meneliti alasan rayuan dan hujahan pihak-pihak, kami berpendapat hanya satu isu sahaja yang perlu kami ulas iaitu **sama ada Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta undang-undang dan hukum syarak di dalam penentuan hak lawatan, bersama dan bermalam bersama dengan anak yang tidak berada di dalam jagaanya.**

9. Isu ini berkait dengan alasan 1 hingga 3 Perayu. Dalam kes ini, YA Hakim Bicara telah memerintahkan seperti berikut:-

“Defendan (bapa) hendaklah diberikan hak lawatan dan bermalam ke atas anak yang bernama Mohsin bin Salihin (No. My Kid : 120406-10-1933) pada hujung minggu kedua dan keempat setiap bulan bermula dari jam 12.00 tengahari Jumaat dan hendaklah dikembalikan semula kepada Plaintiff pada hari Ahad jam 6.00 petang dengan urusan pengambilan hendaklah dimaklumkan kepada Plaintiff terlebih dahulu.

Defendan (bapa) hendaklah diberikan hak lawatan ke atas anak yang bernama Mohsin bin Salihin (No. My Kid : 120406-10-1933) pada hari Isnin dan pada hari Isnin dan Rabu minggu pertama dan minggu ketiga serta hari Selasa dan Khamis minggu kedua dan keempat setiap bulan antara jam 6 petang sehingga jam 9 malam dengan memaklumkan terlebih dahulu kepada Plaintiff.”

10. Perayu berhujah bahawa Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi undang-undang dan fakta apabila memutuskan hak lawatan dan hak bermalam ke atas anak yang ketiga tersebut tanpa mengambil keterangan dan/atau fakta dari Plaintiff dan hanya mengambilkira cadangan dan/atau permintaan Defendan.

11. Perayu juga berhujah bahawa Yang Arif hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta apabila memutuskan hak lawatan dan hak bersama anak ketiga tersebut tanpa mengambilkira jadual persekolahan dan kelas tambahan anak tersebut dan tidak mengutamakan kemaslahatan dan kebajikan anak ketiga tersebut apabila telah menetapkan waktu lawatan bersama dengan Responden pada waktu malam tanpa mengambilkira keperluan lain seperti keperluan atas pelajaran dan waktu rehat pada waktu tersebut.

12. Responden dalam hujahnya pula menyatakan bahawa kelayakan Responden berhubung hak lawatan dan bermalam anak ketiga tersebut bukanlah satu isu yang menjadi pertikaian kerana Perayu di dalam keterangannya tidak pernah menafikannya atau menidakkan isu ini, sebaliknya yang menjadi pertikaian adalah mengenai tempoh masa yang diberikan kepada Responden bagi hak lawatan dan bermalam Responden bersama dengan anak ketiga tersebut sepertimana yang telah didakwa oleh Perayu di dalam perenggan 14 dan 16 hujahan bertulis Perayu.

13. Setelah kami meneliti hujah-hujah dan Rekod Rayuan, kami dapati Perayu sebagaimana di dalam afidavit keterangan Perayu/Plaintif di halaman 27 Rekod Rayuan menyatakan seperti berikut :-

S20: “Jika Mahkamah membenarkan hak jagaan anak ketiga kepada puan, adakah puan membantah Defendan diberikan hak bersama dan bermalam dengan anak tersebut?”

“ Tidak, bukan setakat anak yang ke tiga, malahan saya telah memberikan Defendan untuk bersama dengan anak pertama dan anak ke-2 sejak dari mula saya failkan tindakan perceraian sehingga Defendan mengambil mereka dari saya”

14. Berdasarkan kenyataan di atas, jelas di sini bahawa Perayu tidak membantah atau menafikan hak Responden untuk bersama dan bermalam dengan anak ketiga tersebut.

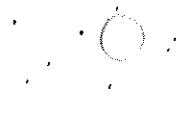
15. Merujuk kepada nota keterangan muka surat 95, dan 98-100 Rekod Rayuan, ketika soal balas keterangan Defendan, tiada isu berkaitan jadual waktu persekolahan, kelas tambahan, keperluan atas pelajaran dan waktu rehat anak ketiga tersebut atau bantahan terhadap cadangan berhubung dengan hak melawat, bersama dan bermalam oleh Plaintiff/Perayu terhadap Defendan /Responden.

16. Kami dapati juga di dalam kes ini, beban untuk membuktikan ketidaklayakan Responden mendapat hak untuk bersama dan bermalam bersama-sama dengan anak ketiga tersebut adalah ditanggung oleh pihak Perayu berdasarkan seksyen 73 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Selangor 2003. Seksyen 73 tersebut berbunyi:

Seksyen 73. Beban membuktikan.

(1) Sesiapa yang berhasrat supaya mana-mana Mahkamah memberikan penghakiman tentang apa-apa hak atau tanggungan di sisi undang-undang yang bergantung kepada kewujudan fakta yang ditegaskan olehnya, mestilah membuktikan bahawa fakta itu wujud.

(2) Apabila seseorang terikat untuk membuktikan kewujudan apa-apa fakta, maka dikatakan bahawa beban membuktikan terletak pada orang itu.



17. Di dalam kes ini, beban untuk membuktikan ketidaklayakan Responden untuk mendapat hak bersama dan bermalam adalah ditanggung oleh pihak Perayu. Oleh kerana Perayu telah gagal membuktikan ketidaklayakan Responden tersebut, maka hak tersebut hendaklah dikekalkan.

18. Kami telah meneliti Alasan Penghakiman Hakim Bicara di halaman 176 Rekod Rayuan dan mendapati di perenggan 26 dan 27, Mahkamah menyatakan seperti berikut:-

“Mahkamah berpendapat adalah tidak wajar hak lawatan dan bermalam pada setiap hujung minggu diberikan kepada Defendan serta hak lawatan ketika persekolahan dengan kekerapan secara umum yang tidak ditentukan masa dan harinya diberikan kepada Defendan. Ini kerana akan memberi ruang kepada Defendan datang melawat anak terlalu kerap atau setiap hari sehingga menimbulkan masyaqaah kepada Plaintif dan anak tersebut yang terpaksa menerima kehadiran Defendan setiap hari tanpa dijadualkan. Oleh itu, Mahkamah melihat hari lawatan Defendan terhadap anak ketiga hendaklah diselang selikan dan bukan setiap hari seperti yang dipohon”.

“ Masa yang sesuai untuk membolehkan Defendan melawat anak ketiga tersebut adalah selepas waktu kerja Plaintif iaitu anatra jam 6.00 petang hingga jam 9.00 malam. Mahkamah melihat tempoh masa 3 jam ini adalah mencukupi dan munasabah kerana ini tidak akan mengganggu waktu peribadi pihak-pihak....”

“Berkenaan dengan hari lawatan pada hujung minggu, Mahkamah melihat hari Jumaat hingga Ahad minggu kedua dan keempat adalah waktu yang sesuai diberikan hak lawatan kepada Defendan...”

19. Oleh yang demikian, kami mendapati YA Hakim Bicara telah mengulas dengan terperinci berhubung dengan terma-terma perintah berkaitan hak lawatan telah ditetapkan. Di dalam isu ini, kami tidak dapat mempertimbangkan hujah-hujah Perayu kerana pada hemat kami terma-terma hak lawatan dan bermalam yang ditetapkan telah mengambilkira semua hal keadaan berkaitan Perayu, Responden dan juga anak tersebut. Suka kami tegaskan di sini, apa-apa perintah berkenaan jagaan dan lawatan anak boleh dimohon ubah pada bila-bila masa tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan di bawah seksyen 76 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Selangor) 2003.

20. Seterusnya Perayu berhujah bahawa Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum syarak kerana menurut *Kitab Fiqh & Perundangan Islam Jilid IV oleh Wahbah Zuhaili*, tidak dibincangkan berkenaan garis panduan di dalam penentuan hak lawatan, bersama dan bermalam dan hanya dibincangkan berkenaan hak menziarahi anak yang tidak berada di dalam jagaannya. Persoalannya adakah menjadi kesalahan seorang hakim membuat keputusan hak untuk bersama dan bermalam dengan anak-anak yang tidak di bawah jagaannya?

21. Hasil penelitian kami, walaupun tiada peruntukan undang-undang dan hukum syarak yang menyebut secara spesifik berhubung hak bermalam namun mengikut kaedah uruf dan di dalam perintah-perintah hadanah hakim-hakim syarie sebelum ini juga, telah meluluskan permohonan berkaitan hak bersama, dan hak bermalam dengan anak-anak yang tidak dalam hak jagaannya. Di samping itu,

Mahkamah juga mempunyai kuasa budi bicara dalam menyelesaikan pertikaian penjagaan anak sebagaimana dalam seksyen 88 2(c) dan (d) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

22. Pada pandangan kami, Responden juga berhak untuk mendapat hak bersama dan bermalam dengan anak ketiga tersebut memandangkan anak tersebut tidak di bawah jagaanya, bahkan perintah yang diputuskan oleh Yang Arif Hakim Bicara adalah perintah yang relevan dan wajar demi menjaga hubungan silaturahim dan memberi ruang kepada Responden untuk menjalankan tanggungjawab mendidik anak ketiga tersebut serta dapat mengeratkan hubungan yang rapat dengan adik beradik yang lain. Kami tegaskan bahawa hak bermalam yang diberikan kepada ibu atau bapa yang tidak diberikan hak jagaan tersebut adalah merupakan suatu tuntutan yang wajar dan munasabah yang tidak wajar dipertikaikan oleh Perayu di dalam kes ini memandangkan berdasarkan perundangan keluarga Islam di Mahkamah-mahkamah Syariah, tuntutan berhubung hak bermalam adalah dibenarkan berdasarkan keperluan yang difikirkan suaimanfaat oleh Mahkamah.

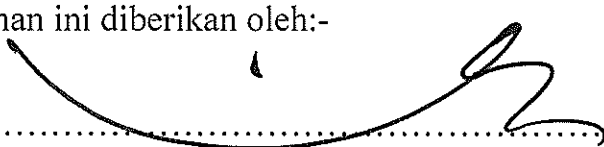
23. Oleh yang demikian, berdasarkan ulasan-ulasan tersebut, kami berpuashati bahawa Perayu tidak dapat menunjukkan kepada kami kehilafan YA Hakim Bicara yang mewajarkan kami untuk campurtangan di dalam perintah tersebut.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Alasan Rayuan, Rekod-Rekod Rayuan dan setelah mendengar dan meneliti hujah-hujah kedua-dua belah, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:-

1. Rayuan Perayu ditolak.
2. Penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di dalam kes no. 10400-028-0038-2015 bertarikh 17/4/2017 adalah dikekalkan.

Penghakiman ini diberikan oleh:-

- 
.....
1. **YAA Tuan Hj Saarani bin Ismail**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
.....
2. **YA Prof. Adjung Dato' Dr Hj. Mohd Naim bin Hj. Mokhtar**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
.....
3. **YA Tuan Hj. Mohd Amran bin Mat Zain**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

